

<제14장 쟁의행위.제8절 쟁의행위와 노사당사자 간의 법률관계>

I. 파업과 근로계약관계

1. 학설

(1) 해지설

- 파업은 근로자의 주된 의무인 노무 제공 의무를 집단적으로 거부하는 행위이므로, 근로계약을 일방적으로 해지하는 의사표시로 보아 근로계약관계가 종료된다는 견해이다. 그러나 이는 단체행동권을 지나치게 위축시켜 노동 3권 보장의 취지에 어긋난다는 비판이 있다.

(2) 정지설

- 파업은 노동조합의 주장 관철을 위한 일시적인 행위로서, 노무 제공 의무와 임금 지급 의무 등 주요 의무의 이행만을 일시적으로 정지시키고, 근로계약관계 자체는 유지된다는 견해이다.

(3) 파기설

- 파업을 근로계약의 주요 내용인 노무 제공 의무를 이행하지 않는 상태로 보아, 계약의 이행이 파기되었으나, 근로계약관계 자체는 존속하는 것으로 보는 견해이다.

2. 검토

- 정지설이 판례의 태도이며 가장 타당하다고 판단된다. 파업은 노동 3권 중 단체행동권의 정당한 행사로서 헌법적 정당성을 가지며, 그 목적은 근로조건의 유지·개선에 있지 근로계약관계의 종료에 있지 않다. 따라서 파업 기간 중에는 노무 제공 의무와 임금 지급 의무가 정지되지만, 파업 종료 후에는 근로계약관계가 자동적으로 회복된다고 보는 것이 노동법의 취지에 부합한다.

II. 쟁의행위와 임금관계

1. 파업과 임금관계

(1) 파업참가자의 임금

① 무노동 무임금 원칙

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제44조 제1항은 쟁의행위로 인하여 근로를 제공하지 아니한 근로자에 대하여는 임금을 지급할 의무가 없다고 규정하여 무노동 무임금 원칙을 명시한다. 파업은 근로 제공의 거부이므로, 정당성 유무를 불문하고 원칙적으로 임금 지급 의무가 면제된다.

② 임금삭감의 범위

- 임금은 현실적 근로의 대가에 해당하는 교환적 부분과 근로자의 지위에서 보장되는 보장적 부분으로 나뉘고, 파업참가자는 보장적 부분의 임금은 청구할 수 있다는 일부삭감설과 임금은 모두 근로의 대가로 지급된다는 점에서 모두 삭감할 수 있다는 전면삭감설, 그리고 이는 당사자의 근로계약, 취업규칙 및 단체협약 등의 해석을 통하여 그 내용이 정하여진다는 계약설이 대립하고 있다. 삭감의 범위는 구체적 사정을 고려하여 결정할 문제라는 점에서 기본적으로 계약설이 타당하다고 보인다.

③ 유급휴일 수당

- 유급휴일에 대한 법리는 휴직 등과 동일하게 근로자의 근로제공의무 등의 주된 권리·의무가 정지되어 근로자의 임금청구권이 발생하지 아니하는 쟁의행위인 파업에도 적용된다 할 것이므로 근로자는 파업기간 중에 포함된 유급휴일에 대한 임금의 지급은 구할 수 없다 할 것이다.

(2) 파업비참가자의 임금과 휴업수당

① 임금

- 근로를 제공한 경우에는 조합원 여부와 관계없이 당연히 임금청구권을 갖는다. 반면, 근로를 제공하지 않은 경우에는 당연히 임금청구권을 갖지 못한다.

② 휴업수당

- 노동조합의 부분파업으로 조합이 불가능한 경우, 파업비참가자에 대하여 휴업수당을 지급하여야 하는지가 문제된다. 판례는 쟁의행위로 정상조합이 불가능하여 사용자가 근로기준법 제46조 제2항에 근거하여 노동위원회에 휴업수당 감액을 신청하여 승인을 받아 휴업수당을 지급하지 아니한 경우, 노동위원회의 승인이 정당하다고 판시하고 있다.

2. 태업과 임금관계

(1) 문제점

- 태업은 근로 제공 자체를 거부하는 파업과 달리 불완전한 근로 제공이 이루어지므로, 임금 지급 의무가 완전히 면제되는지 여부가 문제된다.

(2) 판례

- 태업의 경우에도 근로의 질이나 양이 현저히 저하되어 근로계약상 의무를 불완전하게 이행한 것이 명백하므로, 사용자는 태업으로 인해 저하된 근로의 가치에 상응하여 임금 지급 의무를 감액할 수 있다.

III. 파업과 기타의 근로관계

1. 파업과 근로일의 산정

(1) 연차 유급휴가

- 연차 유급휴가를 위한 출근을 산정에 있어 파업 기간은 노무 제공 의무가 정지된 기간으로 본다. 따라서 판례는 정당한 쟁의행위 기간을 결근으로 보지 않고, 소정 근로일수에서 제외하여 출근율을 산정해야 한다고 본다.

(2) 퇴직금 산정

- 파업 기간은 근로계약관계가 유지되는 기간이므로, 퇴직금 산정을 위한 계속 근로 기간에는 포함된다. 다만, 평균임금 산정을 위한 산정 기간에서는 제외될 수 있다.

2. 파업과 산업재해보상보험

(1) 업무상 재해 여부

- 파업 기간 중에 발생한 사고는 원칙적으로 근로 제공 의무가 정지된 상태에서 발생한 것이므로 업무상 재해로 보기 어렵다.

(2) 예외

- 판례는 파업 기간 중이라도 사용자의 시설 관리하에 노동조합의 본래 업무 또는 사업장 시설 관리와 밀접한 관련이 있는 활동을 수행하던 중 발생한 사고에 대해서는 업무상 재해로 인정될 가능성이 있다고 본다.

IV. 결론

- 파업은 근로계약관계의 주요 의무를 일시적으로 정지시키는 정지설에 따라 근로계약관계가 유지된다. 쟁의행위 기간 중 임금관계는 노조법 제44조에 따라 무노동 무임금 원칙이 적용되어 근로 제공의 대가인 임금의 지급 의무가 면제된다. 파업 기간은 연차유급휴가 산정을 위한 소정 근로일수에서는 제외되지만, 계속 근로 기간에는 포함되는 등 법률관계에 특수한 영향을 미친다.